

1511167-43.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: THAIS FEGURI KRIZANOWSKI FARINELLI

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... local comumente utilizado para tráfico de drogas no município), a forma como embaladas, acondicionadas e escondidas (enterradas no quintal), bem como o fato de o apelante ser conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, denúncia anônima de tráfico de drogas, aliada a confissão de que vendia para alguns "colegas", demonstram a destinação comercial dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511167-43.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511167-43.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAIS FEGURI KRIZANOWSKI FARINELLI

Vistos.

RUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque no dia 10/11/2021, por volta das 09hs15min, na Avenida Maria Francisca de Lima Silva, esquina com a Rua Manoel Raphael, bairro Jardim Regina, nesta cidade e comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 385,6g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahydrocannabinol, substância entorpecente que determina dependência psíquica. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, o denunciado caminhava pela calçada e, ao avistar a aproximação da viatura, mudou repentinamente de direção e escondeu a sacola plástica que trazia nas mãos sob a camiseta que vestia. Abordado por policiais militares e submetido à revista pessoal, constatou-se que na sacola plástica que ele trazia consigo, havia 120 (cento e vinte) porções de maconha com inscrição adesiva identificadora, "letra G", além de um aparelho celular e de R\$ 30,00.

Preso em flagrante delito, houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 58/62). A denúncia foi recebida em 17/12/2021 (fls. 97/99). O réu foi citado (fls. 136) e apresentou defesa preliminar (fls. 129/130).

Na audiência de instrução realizada em 11/04/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e interrogado o réu (fls. 175/180).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação. Pugnou

pela condenação do acusado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, fixando-se a pena-base acima do mínimo legal em razão da personalidade do agente. Entendeu ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como causas de aumento ou de diminuição da pena, devendo ser afastado o privilégio do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Pleiteou a fixação do regime inicial fechado por se tratar de crime equiparado a hediondo. Anotou ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Reiterou seja declarada a perda do dinheiro e do aparelho telefone celular apreendidos (fls. 176/179).

A Defesa, por sua vez, requereu a expedição de ofício ao Hospital de Clínicas para fornecimento do prontuário médico do acusado, a fim de constar lesão e perícia para verificação da capacidade de entendimento por uso de drogas, bem como a absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação das penas nos patamares mínimos, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. Pediu a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 181/195).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não é hipótese de se determinar a expedição de ofício ao Hospital de Clínicas para a vinda de prontuário médico do acusado Ruan Henrique de Oliveira Carvalho (fls. 182), porquanto operada a preclusão, sobretudo porque não requeridas diligências cuja necessidade se originou de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, já encerrada. Ademais, a diligência postulada se entremostra inútil para os fins colimados pela D. Defesa, na medida em que, quando muito, indicaria a lesão, mas não sua autoria, a fim de desqualificar os depoimentos colhidos em Juízo, sob compromisso.

Outrossim, no que tange à submissão do acusado a exame médico-legal (fls. 183), despiciendo a instauração de incidente de insanidade mental para aferir a imputabilidade do acusado, porque em nenhum momento foi alegada pela D. Defesa e inexistente fundada dúvida acerca da higidez mental do réu, não se afigurando suficiente a mera alegação lacônica da parte, em especial porque não detectada nenhuma anormalidade por ocasião da instrução processual ou do interrogatório judicial que justificasse a realização da perícia, conforme inteligência do art. 149 do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passa-se ao exame do mérito. A ação penal é procedente.

A existência material do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ou seja, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), pelos laudos de constatação (fls. 18/20) e de exame químico-toxicológico (fls. 75/78), atestando a natureza da substância apreendida (Tetrahydrocannabinol) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria é certa, conforme prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Com efeito, as testemunhas Marcos Pavarini Junior e Fabien Melo Perassoli, policiais militares, afirmaram em solo policial que efetuavam patrulhamento de rotina pela Rua Manoel Raphael, cruzamento com a rua Maria Francisca Lima Da Silva, bairro Rubens de Abreu Isique, nesta urbe, momento em que avistaram um indivíduo caminhando pela calçada, o qual, ao avistar a aproximação da viatura policial, mudou repentinamente de direção, escondendo a sacola plástica, que trazia nas mãos, sob a camiseta que vestia. Narraram que de imediato referido indivíduo foi abordado, sendo identificado como sendo o acusado Ruan Henrique de Oliveira Carvalho, constatando que dentro da sacola plástica que trazia continha 120 porções de maconha com inscrição adesiva identificadora, "letra G", além de R\$ 30,00 em dinheiro (uma nota de R\$ 20,00 e duas notas de R\$ 5,00) no bolso de trás da bermuda e um aparelho celular da marca LG. Aduziram que, indagado, Ruan Henrique disse que pretendia comercializar a droga no CDHU da Nova Marília, sem, contudo, explicitar de quem teria adquirido os entorpecentes apreendidos (fls. 03/04).

Em Juízo, sob o devido processo legal, as testemunhas ratificaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial. As testemunhas Marcos Pavarini Junior e Fabien Melo Perassoli afirmaram desconhecer o acusado dos meios policiais. Acresça-se que a testemunha Marcos Pavarini Junior esclareceu que ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2002, trabalhando até 2019 na Capital, ano que se mudou para esta cidade de Marília/SP.

A testemunha Fabien Melo Perassoli acrescentou que a letra "G", inscrita na embalagem apreendida, segundo informou o réu, era a designação do bloco do CDHU em que ele comercializaria a droga.

Não há motivos para desmerecer os depoimentos, sobretudo porque o réu não demonstrou que as testemunhas quisessem prejudicá-los gratuita e deliberadamente. Vale dizer que inexistem nos autos dados concretos no sentido de que as testemunhas ouvidas em Juízo, sob compromisso, quisessem mentir.

O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28/4/2020).

Ademais, conforme pontuado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, "Ressalte-se que não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os agentes penitenciários, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente." (Apelação Criminal 1503405-10.2020.8.26.0344; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3.^a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1.^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022).

O réu, por sua vez, admitiu na fase inquisitiva trazia numa sacola plástica a droga apreendida e que ela lhe pertencia, mas se destinava ao seu uso próprio. Negou que pretendia vendê-la a terceiros. Aduziu que adquiriu os entorpecentes com uma pessoa desconhecida nas proximidades do Condomínio São Bento, nesta cidade, às margens da Rodovia, pela quantia de R\$ 300,00, não sabendo informar o significado da inscrição "G" contida nas porções de maconha apreendidas em sua posse (fls. 07).

Interrogado judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática do crime, reiterando a versão apresentada perante a autoridade policial. Afirmou que adquiriu a droga próximo ao São Bento e que era para o seu próprio consumo durante um mês. Disse que lhe ofereceram a mais, para pagar na semana seguinte e que, ao avistar os policiais militares, ficou receoso, facilitando a abordagem da guarnição. Explicou que trabalhava como servente, auferindo renda em média de R\$ 400,00 semanais, convivendo com a mãe, colaborando nas despesas da casa. Esclarece que ela não trabalhava quando de sua prisão, de modo que era o interrogando quem sustentava o lar. Alegou que pagou R\$ 600,00 pela droga, para dois meses, sendo que pagou R\$ 300,00 e ficou devendo a diferença. Pontuou que já foi apreendido na adolescência por tráfico, umas duas ou três vezes. Admitiu que tentou esconder a droga sob a camiseta ao ver a viatura policial, porque ficou com medo. Afirmou já ter morado no CDHU com a mãe e que lá existe um bloco denominado "G", todavia não sabe o significado da inscrição "G" na embalagem da droga que portava. Asseverou que fumava um ou dois cigarros de maconha por dia e que para fazer um cigarro, gastava duas ou três gramas da droga. Aduziu, posteriormente, que morou no São Bento e que deixou o local por ter sido agredido por policiais, em uma boca de fumo, possuindo uma cicatriz na cabeça. Afirmou que foi agredido pelo mesmo policial inquirido em audiência, bem como havia outros policiais, sendo atendido no Hospital de Clínicas. Afirmou já ter sido ameaçado pelo policial. Negou ter dito aos policiais que venderia a droga. Aduziu que estava morando em Padre Nóbrega, no Maracá e que tinha ido ao São Bento na casa de sua tia, a fim de comprar droga. Argumentou que depois da maioridade, não vendeu mais drogas. Disse ser viciado desde os 13 anos de idade, aproximadamente.

Como se vê, não obstante os argumentos defensivos, a prova coligida é robusta e

sustenta o decreto condenatório do réu.

A versão apresentada pelo réu em Juízo restou inverossímil e isolada nos autos, não encontrando qualquer respaldo nos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual. Os depoimentos dos policiais militares foram coesos e harmônicos entre si, descrevendo de forma extrema de dúvidas que o denunciado foi abordado no passeio público trazendo consigo 120 (cento e vinte) porções de maconha, cuja natureza restou comprovada pelo laudo químico-toxicológico coligido aos autos, além de R\$ 30,00 (trinta reais) em espécie e um aparelho celular, sequer demonstrando a origem da quantia apreendida e a respectiva fonte de renda que viabilizasse a aquisição dos entorpecentes por R\$ 300,00, conforme alegado.

Inegável que a droga foi apreendida com o acusado, conforme destacado, amoldando-se a conduta à figura típica de trazer consigo disposta no art. 33 da Lei n.º

11.343/2006. De fato, o réu conduzia pessoalmente a droga. E tratando-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado envolvendo o mesmo objeto material, eventual pluralidade de condutas não descaracteriza o crime, de modo que irrelevante se o acusado adquiriu primeiramente o entorpecente, na medida em que as condutas denotam sucessão de fases de um mesmo ilícito penal.

Diante desse cenário, não há se cogitar em insuficiência probatória (*in dubio pro reo*) ou atipicidade da conduta, tampouco em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

A imputação delimitada na denúncia é no sentido de que o acusado trazia consigo droga, que determina dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, núcleo contido no tipo incriminador do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, delito de caráter permanente cuja consumação ocorre no momento em que o agente realiza a conduta típica, prolongando-se no tempo durante o período em que o agente estava com a droga, autorizando inclusive a prisão em flagrante delito. Por ocasião da abordagem policial, decerto que o réu já trazia consigo a droga, restando consumada a infração penal.

Outrossim, a intenção do tráfico ilícito de drogas restou indubitável em razão da quantidade da droga apreendida, forma de acondicionamento e comportamento do acusado antes da apreensão. O réu trazia consigo 120 (cento e vinte) trouxinhas de plásticos contendo maconha, somando 385,6 gramas (massa líquida - fls. 19), além de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, sendo uma nota de R\$ 20,00 (vinte reais) e duas notas de R\$ 5,00 (cinco reais), além de um aparelho celular da marca LG. De fundamental, a inscrição adesiva identificadora letra "G" na embalagem da droga que trazia consigo, indicativo de que as drogas destinavam à comercialização em bloco do CDHU, local conhecido do acusado, ressoando na prova testemunhal colhida em Juízo.

Ora, por todas essas circunstâncias, somadas à quantidade de droga apreendida, bem como a forma como foi encontrada, forçoso concluir que o réu efetivamente trazia consigo droga para a entrega a consumo de terceiras pessoas.

No mais, a solução legal para se concluir pelo tráfico vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/06. Neste contexto, observa-se que a quantidade de entorpecente apreendida, além da forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão, tudo a revelar a traficância pelo acusado.

Conforme ressaltado, a quantidade de droga encontrada com o acusado era bastante significativa e poderia atingir inúmeros usuários. Ademais, o acondicionamento em pequenas porções individualizadas indica o comércio espúrio de entorpecente.

Ainda que se reputasse o réu usuário, esse fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada obsta que faça uso de entorpecentes e guarde drogas para entrega a terceiros. Além disso, improvável que a quantidade de drogas apreendidas e a forma como embaladas sejam simplesmente destinadas ao consumo do réu, conforme sustentado pela D. Defesa.

Urge anotar, ainda, que a jurisprudência é no sentido de que "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Aludiu-se, inclusive, "que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas

figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas." (C. STJ, REsp n.º 1.708.569 - ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/02/2018).

Como decidido, "A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado, normalmente, é suficiente para configurar o injusto previsto no art. 12 da Lei de Drogas, somente afastado quando o elemento 'para exclusivo uso próprio' encontra relevante respaldo na prova dos autos. O tipo previsto no art. 12 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se o tipo subjetivo no dolo." (C. STJ, REsp n.º 347.909/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.T., j. 05/02/2002, DJ 04/03/2002, p. 290).

Destaca-se que o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de que "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp n.º 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6.T., j. 10/6/2014).

Aliás, sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3.^a ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico de drogas, a Lei n.º 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, considerando o disposto nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, assim como dos artigos 42 e 43, ambos da Lei n.º 11.343/2006, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente, observa-se que o réu não ostenta Maus antecedentes (fls. 35) e a culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos sobre má conduta social. As consequências e circunstâncias do crime não ultrapassam as particularidades do próprio tipo penal. Não há que falar em comportamento da vítima (crime de perigo abstrato), ao passo que a natureza da droga de menor poder vulnerante é normal, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Anote-se que os atos infracionais praticados durante a menoridade do acusado (fls. 50/61) não podem ser considerados como geradores de antecedentes, tampouco podem servir para caracterizar personalidade desajustada ou má conduta (C. STJ, HC n.º 499987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.^a T., DJ 30.05.2019).

Ausentes circunstâncias agravantes na segunda fase. Presente a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, ou seja, ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato (fls. 22). Todavia, insta consignar a impossibilidade de valoração da menoridade penal relativa, porquanto as penas já se encontram nos menores patamares legalmente permitidos (C. STJ, Súmula n.º 231).

Na terceira fase da dosimetria penal, ausentes causas de aumento da pena. Deixo de

aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, pois a quantidade de droga e a apreensão de dinheiro sem a comprovação de origem lícita e os inúmeros registros na Vara da Infância (fls. 36/37), são indicativos de que o acusado se dedica à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do redutor.

Nesse sentido:

"Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Insurgência da Defesa – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Inteligência do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 – Mercancia demonstrada – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – Não cabimento – Circunstâncias da prisão, local da abordagem (apelante pulando o muro do cemitério, local comumente utilizado para tráfico de drogas no município), a forma como embaladas, acondicionadas e escondidas (enterradas no quintal), bem como o fato de o apelante ser conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, denúncia anônima de tráfico de drogas, aliada a confissão de que vendia para alguns "colegas", demonstram a destinação comercial dos entorpecentes – Dosimetria: Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) – Segunda fase – Presente a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, porém sem reflexos na pena, ante o teor da Súmula 231, STJ – Terceira fase – Redutor não aplicado – Conquanto o acusado seja tecnicamente primário e não tenha antecedentes criminais, observa-se que ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude por prática de ato infracional, tendo inclusive cumprido medida socioeducativa, o que constitui circunstância impeditiva da aplicação da benesse do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que seguramente indicativa de sua dedicação a atividades criminosas – Regime fechado alterado para o semiaberto – Nem se cogite de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I, CP – Recurso provido em parte para fixar o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença." (E. TJSP; Apelação Criminal 1500667-12.2021.8.26.0539; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13.ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2022; Data de Registro: 05/04/2022). (destaquei)

"PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO. Ministério Público. Pretendida a fixação de regime inicial fechado. Inadequação. Circunstâncias que justificavam, perfeitamente, o regime semiaberto imposto. Maior rigor não adequadamente justificado. Mantida, portanto, a r. sentença, prevalecendo o parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social, aplicando-se o artigo 33, §2º, "b" e §3º, do Código Penal. E pelos mesmos motivos acima ventilados, mostra-se inadequada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (artigo 44, III, do Código Penal), tampouco seria o caso de concessão de "sursis" (artigo 77, §2º, do mesmo codex). Alison. Pretendida a nulidade da sentença, por decisão proferida pelo E. STJ. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação para o delito de uso próprio, aplicação do redutor do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, fixação de regime aberto e substituição da pena. Descabimento. 1. Nulidade da sentença. Decisão do E. STJ. Inocorrência. Conforme decidido pelo C. STJ em HC impetrado, foram anuladas as provas do processo obtidas pelo ingresso desautorizado da polícia no domicílio. Contudo, apreensão de parte do entorpecente dentro do veículo do réu, estacionado na via pública, ou seja, 30 porções de maconha. Impossibilidade de se estender decisão, específica e clara, do C. STJ. Provas produzidas pelo encontro dos entorpecentes no carro que não foram contaminadas pelo ingresso considerado irregular no domicílio. Afastada a nulidade. 2. Absolvição. Impossibilidade. Delito e autoria encontram-se demonstrados pelos corretos e coesos depoimentos prestados pelo réu, bem como a admissão do encontro das 30 porções de maconha, pela testemunha Evelyn, dentro do automóvel do réu. Além disso, não demonstrou ter condições de adquirir-las para seu uso, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de uso próprio. 3. Aplicação do redutor do §4º, do

art. 33 da Lei 11.343/06. Inviabilidade. Réu que ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por prática de atos infracionais enquanto menor, evidencia a dedicação as atividades criminosas e afasta o privilégio no tráfico de drogas por falta de preenchimento dos requisitos cumulativos enumerados no §4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Precedentes. 4. Regime aberto e substituição da pena corporal. Descabimento. Apesar de ser criminoso primário, sem antecedentes, apresentou atos infracionais, quando menor, relativos ao delito de tráfico de drogas. Desse modo, se fixado regime aberto, seria um incentivo para que prosseguisse no cometimento do vil comércio, de modo que correto seja mantido o regime semiaberto como forma do Estado poder exercer vigilância de seu comportamento (art. 33, §2º, "b" e §3º, do CP). E pelos mesmos motivos, inadequado e insuficiente seria a substituição da pena corporal, bem como da concessão de "sursis" (art. 44, III e art. 77, II, ambos do CP). Negado provimento." (E. TJSP; Apelação Criminal 1500491-61.2019.8.26.0617; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9.ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5.ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022). (destaquei)

Mantenho, desta forma, a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, porque o acusado, quando inimputável, já teria registrado reiterado envolvimento infracional por ato equiparado ao crime de tráfico de drogas, conforme se extrai da certidão de fls. 36/37 e por ele próprio aduzido por ocasião de seu interrogatório judicial, a justificar a incidência do regime mais gravoso previsto em lei, porque maior o grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista o princípio da suficiência, nos termos do art. 33 do Código Penal, a obstar a utilização de simples cálculo aritmético para fins de regime inicial de pena.

A conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena ao réu são incabíveis por falta de preenchimento dos requisitos objetivos a que aludem os artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos. A teor da Lei 12.736/12, que incluiu o § 2.º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração de pena, com a consequente progressão de regime, deverá ser oportunamente analisada em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos, inclusive porque o acusado trouxe informações acerca de eventual apuração de falta disciplinar, a implicar o elemento subjetivo (fls. 182, último parágrafo).

Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto da conduta praticada demonstra a necessidade de continuidade da custódia. Afinal, trazia consigo expressiva quantidade de droga, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face do crime e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

O réu permaneceu preso durante todo o processo para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação.

Assim é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes." (RHC n.º 117.802, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2.T., j. 10/06/2014, DJe 01/07/2014).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR RUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Mantida a prisão preventiva do réu, recomendem-se o custodiado no estabelecimento prisional em que se encontrar.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, letra "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intime-se pessoalmente, para efetuar o recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando suspensa a exigibilidade caso seja beneficiário da gratuidade da justiça.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução das penas impostas.

Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Declaro o perdimento, em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, do valor apreendido (R\$ 30,00 - trinta reais), conforme auto de exibição/apreensão, por ausência da comprovação da origem lícita do dinheiro, bem como do aparelho celular (fls. 11/12), utilizado na prática do comércio espúrio, como consequência da condenação. Oficie-se.

Comunique-se a autoridade policial para que providencie a destruição da droga apreendida, contraprovas e eventuais embalagens, apetrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos termos do art. 72 da Lei n.º 11.343/06, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA